



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/296/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין
ציפי קוינט שילוני

1	שחר עדית, ת.ז. 033079609	תובעים
2	שחר שפונד אמיר, ת.ז. 038231759	
3	סדון חנה, ת.ז. 056648413	
4	סדון מיכאל, ת.ז. 069473726	
	באמצעות ב"כ: עו"ד בני גאנוניאן אברבנאל 21, ירושלים	

נגד

1	בן עזרא ירון, ת.ז. 034200105	נתבעים
2	בן עזרא רווית, ת.ז. 033594136	
3	קמחי יוסף, ת.ז. 027177146	
4	קמחי דריה, ת.ז. 304548993	

באמצעות ב"כ: עו"ד סיגלית הנדשר פרקש
השדרה המרכזית 15 (בנין ליגד 1), מודיעין-מכבים-רעות

פסק דין

עניינו של פסק דין זה בפרשנות סעיף בתקנון מוסכם של הבית המשותף ובעיקר בשאלה מהו היקף הבניה שרשאים הנתבעים לבנות בלי לקבל את הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף.

א. העובדות הצריכות לענין:

1. עניין לנו בבית משותף המצוי במקרקעין הידועים כגוש 5568 חלקה 25 ברחוב רא"ל דוד אלעזר 46, 48, 50, 52, 54 ובהתאמה ברחוב חטיבת הראל 22, 24, 26, 28 וכן ברחוב רא"ל חיים לסקוב 12 בעיר מודיעין-מכבים-רעות (להלן: "הבית המשותף"). המדובר בבית מורכב כמשמעו בסעיף 59(א) לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"). הבית המשותף מורכב מארבעה מבנים ומונה 60 דירות. למבנים 1 ו-4 ישנן 2 כניסות א' ו-ב', למבנים 2 ו-3 ישנן 3 כניסות א'-ג'. לבית המשותף נרשם תקנון מוסכם ביום 20.5.2001.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/296/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התביעה דן עניינה במבנה 1 כניסה ב' ברחוב דוד אלעזר 48 בו מצויות 6 דירות ב-3 קומות (חלקות משנה 7-12).

2. התובעים 1 ו-2 הם בעלי הזכויות בדירה מספר 1 הידועה כחלקת משנה 7 בשטח של 99.03 מ"ר המצויה בקומת הקרקע של הבית המשותף. התובעים 3 ו-4 הם בעלי הזכויות בדירה מספר 2 הידועה כחלקת משנה 8 בשטח של 99.03 מ"ר המצויה אף היא בקומת הקרקע. הנתבעים 1 ו-2 הם בעלי הזכויות בדירה מספר 5 הידועה כחלקת משנה 11 בשטח של 66.05 מ"ר המצויה בקומה השנייה. נתבעים 3 ו-4 הם בעלי הזכויות בדירה מספר 6 הידועה כחלקת משנה 12 בשטח של 66.05 מ"ר המצויה אף היא בקומה השנייה של הבית המשותף.

3. על פי נסח רישום המקרקעין לתובעים 1 ו-2 10/540 חלקים ברכוש המשותף. גם לתובעים 3 ו-4 10/540 חלקים ברכוש המשותף. לנתבעים 1 ו-2 7/540 חלקים ברכוש המשותף. אף לנתבעים 3 ו-4 7/540 חלקים ברכוש המשותף.

4. מכתב התביעה שהוגש על ידי התובעים ביום 18.7.17 עולה, כי הנתבעים הגישו בקשה לתוכנית בניין עיר (תב"ע מספר 420-0243220 מד/מק/2/23) (להלן: "התב"ע") במטרה להוסיף שטחים לדירותיהם, בין היתר, על גבי הגג המשותף בו מצויים מתקנים משותפים לכלל בעלי הדירות בבית המשותף כגון: קולטי שמש, מזגנים וכיוצא בזה. מטרת התב"ע היא הוספה של 65 מ"ר לדירותיהם של הנתבעים על גג הבית המשותף, הארכה והגבהת גרם המדרגות המשותף, בניה מעל למרפסת המצויה בדירות הנתבעים אשר מוצעת סגירתה, הוספת מדרגות פנימיות בדירות הנתבעים והוספת חניות על גבי הרכוש המשותף. התב"ע הוגשה לגבי כל הבניינים המצויים בחזית רחוב רא"ל דוד אלעזר (46-54 זוגי). התובעים הגישו התנגדות לתב"ע אך היא נדחתה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה במודיעין בטענה כי מדובר בהתנגדות קניינית ועליה להתברר בערכאות המוסמכות לכך. ביום 28.7.16 ניתן תוקף לתב"ע.

5. הנתבעים הגישו בקשה להיתר בניה בהתאם לתב"ע. התובעים הגישו התנגדות לבקשת ההיתר. ההתנגדות נדחתה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בטענה כי מדובר בהתנגדות קניינית שאין הוועדה המקומית דנה בה.

6. ביום 11.9.17 הגישו התובעים תביעה זו שעניינה מניעת הבניה שאושרה לנתבעים על ידי הוועדה המקומית. בד בבד עם הגשת התביעה הוגשה בקשה למתן צו מניעה זמני. צו כאמור ניתן על ידי כב' המפקחת פריאנטה בהחלטתה מיום 19.7.17. ביום 25.7.17 הגישו הנתבעים בקשה לביטול צו המניעה הזמני, דיון בבקשה התקיים ביום 27.7.17 בסופו של דיון זה ובהמלצת כב' המפקחת פריאנטה, אשר החלה לדון בתיק זה ובהמשך הוא עבר לטיפול, הסכימו הצדדים כי בשלב זה ינתן צו מניעה זמני. לפיכך נקבע בהחלטה מאותו היום כי צו המניעה הארעי שניתן ביום 19.7.17 יוותר על כנו עד לתום ההליך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/296/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. המחלוקת בין הצדדים נטועה בעיקרה בפרשנות סעיף 3 לתקנון המוסכם ובשאלה האם הוראותיו מאפשרות לנתבעים לבצע את הבניה על פי ההיתר ללא קבלת הסכמות פרטניות של בעלי הדירות בבית המשותף, הסעיף הרלוונטי יובא להלן:

”כל בעל דירה יהיה רשאי בכפיפות לתנאי חוזה חכירה, להוסיף תוספת בניה לדירתו ובתנאי שקיבל תחילה את הסכמת מנהל מקרקעי ישראל והרשויות המוסמכות לתכנון ולבניה ובתנאי שהשטח הכולל של דירתו ושל תוספת הבניה שביצע ו/או שברצונו לבצע לא יעלו על חלקו באחוזי הבניה המרביים המותרים ו/או המאושרים לחלקה בשלמותה וחלקו זה יהיה כחלקה של דירתו ברכוש המשותף של הבית המשותף. הסכמת יתר בעלי הדירות בבית המשותף לבניית תוספת כלעיל, נתונה בזאת מראש. עם תום הבניה יהא המבקש רשאי לפנות למפקח על רישום המקרקעין ולבקש תיקון צו רישום הבית המשותף, וזאת על מנת ליתן ביטוי משפטי לשינויים הפיזיים שחלו עקב הבניה הנוספת וההסכמה של בעלי הדירות האחרות נתונה מראש.”

ב. תמצית טענות הצדדים:

טענות התובעים

8. טענתם העיקרית של התובעים היא כי למרות סעיף 3 לתקנון הנתבעים אינם יכולים לבנות כלל וזאת כיון שלנתבעים אין את ההסכמה הנדרשת על פי החוק לבניה המבוקשת על ידם. לטענתם הבניה המבוקשת בגג הבית המשותף וכן בקשתם לשתי חניות נוספות על גבי הרכוש המשותף מצריכות הסכמה של לפחות 75% מכלל בעלי הדירות בבית המשותף ששני שליש מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם זאת בהתאם לסעיף 71ב לחוק המקרקעין. לשיטתם יש לבצע את חישוב אחוזי ההסכמה בהתאם לסעיף 4 לתקנון המוסכם שכותרתו ”הפרדת הרכוש המשותף למבנים וכניסות” ולפיו **”כל חלקי הרכוש המשותף שבתחום כל כניסה... יהיו צמודים לדירות שבאותה הכניסה בלבד”** כך שיש לבחון את הרוב הדרוש מהכניסה הספציפית בה גרים הצדדים להליך זה. בכניסה ב' המצויה במבנה 1, היא הכניסה בה מתגוררים הצדדים דנן, מצויות 6 דירות משכך לשיטת התובעים יש לנתבעים הסכמה של 66.66% לכל היותר, זאת בשל העובדה כי התובעים עצמם מהווים 33.33% מבעלי הדירות בבית המשותף, על כן אין בידי הנתבעים את ההסכמה הנדרשת בחוק המקרקעין. לטענת התובעים מטעם זה בלבד דין התביעה להתקבל ואין לאפשר לנתבעים לבנות כלל. כך גם נטען על ידי התובעים כי כל גריעה מן הרכוש המשותף חייבת להיעשות באופן מפורש וכי בתקנון המוסכם אין כל הוראה מפורשת כזו. לטענת התובעים אומנם סעיף 3 לתקנון המוסכם מקים מנגנון המאפשר לבעלי זכויות בבית המשותף תוספות בנייה, אולם אין המדובר בסעיף המתיר באופן מפורש בנייה על גבי הרכוש המשותף. לפיכך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/296/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לא ניתן ללמוד מסעיף זה בשום פנים ואופן כי ניתן לבנות בניה כלשהי ללא הסכמת בעלי הדירות על פי חוק המקרקעין.

9. ככל שלא תתקבל טענתם זו, טוענים התובעים באופן חלופי כי בהתאם לסעיף 3 לתקנון המוסכם של הבית המשותף מוגבלים הנתבעים לבניה לפי חלקם ברכוש המשותף כך שסך השטחים העיקריים בדירתם לא יעלה על 89.28 מ"ר ומעבר לכך נדרשת הסכמת בעלי הדירות על פי חוק המקרקעין. לשיטת התובעים לשון סעיף 3 היא ברורה וחד משמעית וממנה עולה פרשנות זו. התובעים מפנים לתקנון התב"ע אותה יזמו הנתבעים ממנו עולה כי לפני אישור התב"ע קיימים 6,300 מ"ר בנוי על החלקה ועל פי התב"ע רוצים להוסיף 588 מ"ר עולה אפוא כי סל זכויות הבניה (שטח עיקרי) לאחר התב"ע עומד על 6,888 מ"ר שטח עיקרי. חלקה של כל אחת מדירות הנתבעים ברכוש המשותף עומד על 7/540. חלק זה כשהוא מוכפל בסך זכויות הבניה מביא לכך שלא ניתן לבנות יותר מ-89.28 מ"ר שטחים עיקריים בכל דירה כששטח זה כולל כמובן את מה שכבר בנוי ואת מה שמתבקש לבנות. הנתבעים מפנים בעניין זה לנספח א' לכתב ההגנה אשר הינו טבלת חישובי שטחים כפי שהוגשה על ידי האדריכלית נעמי גלברט מטעם הנתבעים לועדה המקומית. על פי נספח זה השטח העיקרי הבנוי היום בדירות הנתבעים עומד על 73.77 מ"ר ולפיכך כל שנותר לנתבעים לבנות כעת הוא שטח עיקרי של $89.28 - 73.77 = 15.51$ מ"ר. על פי ההיתר שניתן לנתבעים אושרה תוספת בניה בשטח של 69.09 מ"ר עיקרי לכל דירה וזאת אין להתיר. לשיטת התובעים לא בכדי בחרו הנתבעים שלא להעיד את האדריכלית נעמי גלברט אשר היא זו שהגישה עבורם את התוכניות לועדה המקומית והעדרה ממסכת העדויות מובילה למסקנה ברורה שלו היתה מעידה, היתה פועלת עדותה לרעת הנתבעים.

10. לטענת התובעים כחלק מתנאי היתר הבניה נדרשים הנתבעים להקצות שני מקומות חניה בשטח המשותף. לשיטת התובעים לשם חניית אלה נדרשת הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף כולם (כל ה-60). התובעים טוענים כי גם אם אין המדובר בחניות המוצמדות לדירות הנתבעים אלא בחניות בהן יוכלו לחנות כלל בעלי הדירות נדרשת הסכמת כלל בעלי הדירות בבית המשותף וזאת אינה קיימת.

11. לסיום טענותיהם הפנו התובעים לסעיף 7 לתקנון הבית המשותף בו נקבע כי: **"לא תותר על בעלי הדירות או מטעמם לעשות שינויים בקירות החיצוניים של הדירה ובחזיתותיה לרבות פתחים ו/או חלונות מבלי שיקבלו הסכמה מראש ובכתב של נציגות הבית המשותף ובנוסף לכך מבלי שיקבלו רישיונות ו/או היתרים הדרושים לכך על פי דין"**. מסעיף זה עולה, לטענתם, כי הבניה אותה מבקשים הנתבעים לבצע אסורה אף מכוחו של סעיף זה שכן היא כוללת פתחים וחלונות ולא הוצג כל אישור לכך מטעם נציגות הבית המשותף.

טענות הנתבעים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/296/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. לטענת הנתבעים אין כל מקום לקבל את טענתם העיקרית של התובעים לפיה לכל בניה ברכוש המשותף נדרשת הסכמת הרוב כקבוע בסעיף 71ב לחוק המקרקעין. פרשנות כזו אינה עולה בקנה אחד עם סעיף 3 לתקנון הבית המשותף והיא תהפוך אותו לאות מתה ותעקר אותו מתוכן. לטענתם סעיף 3 לתקנון המוסכם התווה דרך להרחבת הדירות בבית המשותף תוך שניתנת הסכמה מראש של בעלי הדירות להרחבת הדירות. התקנון המוסכם הוא בגדר הסכם בין בעלי הדירות אשר יש לפרשו על פי אומד דעתם של הצדדים להסכם. לטענת הנתבעים הפרשנות הסבירה וההגיונית שיש ליתן להוראת סעיף 3 לתקנון המוסכם היא כי ניתנה הסכמה מפורשת מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף לכך שבעל דירה יהא רשאי להרחיב דירתו וזאת לפי חלקו ברכוש המשותף. כן טענו כי הפרשנות אותה מציעים התובעים תביא לכך שרק בעלי דירות הגן להן מוצמדת חצר יוכלו לעשות שימוש בסעיף זה ולבנות וזה לא יתכן. כדי להצביע על אומד דעת הצדדים לתקנון הפנו הנתבעים לסעיפים מתוך הסכמי הרכישה עם הקבלן העוסקים באפשרות שהקבלן יצמיד את כל זכויות הבניה לו או למי מבעלי הדירות. לשיטתם טועים התובעים עת מפנים הם לסעיף 71ב לחוק המקרקעין וטועים כפליים שעה שמחשבים את הרוב הדרוש מן המבנה הספציפי ולא מתוך כלל בעלי הדירות בבית המשותף.

13. באשר לטענה החלופית אשר בפי התובעים טוענים הנתבעים כי היקף זכויות הבניה שהם זכאים לנצל על פי סעיף 3 לתקנון יקבע באופן הבא: שטחי הבניה המרביים החלים על החלקה על פי תב"ע מד/מב/2 (היא התכנית המקורית החלה על הבית המשותף ואשר קדמה לתב"ע אותה קידמו הנתבעים) הם 10,760 מ"ר (שטח עיקרי 6,300 מ"ר שטחי שרות 4,460 מ"ר). חלקם ברכוש המשותף של כל אחד מבעלי הזכויות בדירות העליונות (דירות הנתבעים) הוא 7/540. מנתונים אלו גוזרים הנתבעים את המשוואה הבאה: $10,760 \cdot \frac{7}{540} = 139.48$ מ"ר. על פי חישוב זה הנתבעים רשאים להרחיב את דירתם בלי לקבל הסכמת בעלי הדירות האחרים כך ששטח כל דירה לאחר ההרחבה לא יעלה על 139.48 מ"ר. ההרחבה שאושרה על ידי הועדה המקומית אינה מגדילה את הדירה מעבר ל 139.48 מ"ר ולפיכך הם רשאים לממשה. עוד טענו, כי גם ביתר תנאי סעיף 3 לתקנון הם עומדים הם כיוון שקיבלו היתר בניה. באשר לאישור הנדרש מרשות מקרקעי ישראל נטען כי דירות הנתבעים הן בבעלותם הפרטית ועל כן אין עוד צורך בהסכמת רמ"י.

14. בכל הנוגע לתוספת החנייה המבוקשת על ידי הנתבעים טענו הם כי תוספת החנייה לא תוצמד לדירה זו או אחרת אלא תשמש את כלל בעלי הדירות. לשיטתם השטח עליו מבוקש לבנות את החניות מוזנח ועוזב ובניית שתי חניות על גבי שטח זה מהווה שימוש רגיל וסביר ברכוש משותף אשר ככזה אינו דורש הסכמת בעלי הדירות או הסכמת האסיפה הכללית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/296/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

15. באשר לטענת התובעים בעניין סעיף 7 לתקנון המוסכם טענו הנתבעים כי טענה זו כשהיא מועלית מפי התובעים אשר ערכו שיפוץ נרחב בדירתם, פתחו חלונות, שינו חזיתות היא בבחינת "טובל ושרץ בידו" ודינה להידחות. בנוסף טוענים כי אם תתקבל פרשנות התובעים לפיה נדרשת הסכמת בעלי הדירות לכל שינוי הרי שלמעשה הוראה זו תרוקן מתוכן את סעיף 3 לתקנון המוסכם כיוון שברור שתוספת בניה גורמת לשינויים. בעניין זה הפנו הנתבעים לפסק דינה של כב' המפקחת יעל ליבוביץ בתיק 11/15 אלפרסי ואח' נ' אבי יונגר (פורסם בנבו, 21.4.15).

ג. דיון והכרעה:

16. אקדים אחרית לראשית ואומר כי לאחר ששקלתי טענות הצדדים החלטתי לקבל את התביעה בחלקה ולקבוע כי הנתבעים יוכלו להרחיב את דירתם ללא צורך בהסכמה פרטנית של יתר בעלי הדירות אך זאת בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, כאשר על פי חלק זה יגזרו הן השטחים העיקריים שהנתבעים יוכלו לנצל והן שטחי השירות. מעבר לשטח שיתקבל לפי מפתח זה יהא על הנתבעים לקבל את ההסכמות על פי הרף הקבוע בסעיף 71 לחוק המקרקעין. להלן יפורטו טעמי.

17. כלל ידוע הוא כי תקנון מוסכם הוא בגדר הסכם שנערך בין בעלי הדירות בבית המשותף, ולו מעמד קנייני :

"תקנון מוסכם של בית משותף הוא הסכם בין בעלי הדירות לבין עצמם, ומשנרשם בפנקס הבתים המשותפים ניתן לו מעמד קנייני: הוראותיו מחייבות את כל בעלי הדירות וחליפיהם החוקיים (סעיף 62 (ג) לחוק המקרקעין. התקנון מסדיר את "היחסים בין בעלי הדירות ואת חובותיהם בקשר לבית המשותף..." (רע"א 3463/11 עזבון המנוח אהרונ' שלמה ואח' נ' עופר מרכזים בע"מ (פורסם בנבו 16.1.13). ראה גם: א. אייזנשטיין, "יסודות והלכות בדיני מקרקעין", חלק ג' תשס"א, בעמ' 132-133).

18. נפסק כי ככל הסכם, גם את התקנון המוסכם יש לפרש לפי אומד דעת הצדדים (ראה: ע"א 5043/96 גלמן ואח' נ' הררי-רפול ואח', פ"ד נד(3) 389) על אומד דעת הצדדים נאמר כי :

"אומד דעת זה הוא המטרות, היעדים, האינטרסים, והתכנית אשר הצדדים ביקשו במשותף להגשים. על אומד הדעת למד הפרשן מלשון החוזה ומהנסיבות החיצוניות לו. שני מקורות אלה 'קבילים' הם. בעזרתם מגבש הפרשן את אומד דעתם המשותף של הצדדים" (דברי המשנה לנשיא (כתוארו אז) השופט ברק, ע"א 4628/93 מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון וייזום (1991) בע"מ, פ"ד מט(2) 265 (1995), בעמוד 311- להלן: "עניין אפרופים"). הלכה זו נתאשררה לאחר דיון בהרכב מורחב בדנ"א 2045/05



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/296/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ארגון מגדלי הירקות אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד
סא (2) 1, 2006 (להלן: "עניין ארגון מגדלי ירקות").

19. לאחר שנפסקו ההלכות בעניין אפרופים וארגון מגדלי הירקות לעיל, נחקק תיקון מס' 2 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים"), הקובע את יסודות כללי פרשנותו של הסכם. הוראת סעיף 25(א) לחוק החוזים לאחר התיקון קובעת כך:

"(א) חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו.
(ב) חוזה הניתן לפירושים שונים, פירוש המקיים אותו עדיף על פירוש שלפיו הוא בטל.

(1ב) חוזה הניתן לפירושים שונים והיתה לאחד הצדדים לחוזה עדיפות בעיצוב תנאיו, פירוש נגדו עדיף על פירוש לטובתו.
(ג) ביטויים ותניות בחוזה שנוהגים להשתמש בהם בחוזים מאותו סוג יפורשו לפי המשמעות הנודעת להם באותם חוזים.
(ד) סעיפים 2, 4, 5, 6, 7, 8 ו-10 לחוק הפרשנות, תשמ"א-1981, וסעיף 57 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, יחולו, בשינויים המחויבים, גם על פירוש של חוזה, אם אין הוראה אחרת לענין הנדון ואם אין בענין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור"

20. בפסק דינו של בית המשפט העליון ברע"א 3961/10 המוסד לביטוח לאומי נ' סהר חברה לתביעות בע"מ (פורסם ב"נבו"), נדון תיקון מס' 2 לעיל, כאשר על רקע בחינת ההלכה הפסוקה, הגיע בית המשפט למסקנה כי בהליך פרשנות החוזה, ביקש המחוקק ליתן משקל משמעותי ללשונו-

"(...) עד כאן באשר לתכליתו הסובייקטיבית של סעיף 25(א) המתוקן. כפי שראינו, תכלית זו מצביעה בבירור על כך שהפירוש הנכון לסעיף המתוקן הוא כדלקמן: חוזה יפורש תוך בחינה מקבילה ומשותפת של לשון החוזה ושל נסיבות העניין, בכפוף לחזקה פרשנית – ניתנת לסתירה – שלפיה פרשנות החוזה היא זו התואמת את פשט הלשון, דהיינו: את המשמעות הפשוטה, הרגילה והטבעית של הכתוב. החזקה ניתנת לסתירה במקרים שבהם למד בית המשפט, מתוך הנסיבות, כי הלשון אינה פשוטה וברורה כפי שנחזתה להיות במבט ראשון; וכי למעשה – עשויה היא להתפרש בדרכים אחרות מאלה שנראו ברורות בתחילת הדרך הפרשנית. ודוק: קיומה של החזקה מבטא את משקלה החשוב והמשמעותי של לשון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/296/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החוזה; לעומת זאת, היותה ניתנת לסתירה משקפת את העובדה כי משקלה של הלשון, חרף חשיבותה, אינו מכריע או בלעדי".

21. נוכח המקום המרכזי השמור ללשון החוזה בהליך הפרשני נפסק עוד כי "ככל שלשון החוזה ברורה יותר, כן תידרשנה ראיות-חוץ בעלות משקל כבד יחסית כדי לגבור על הפירוש הנדרש ממנה לכאורה... משקלן הכולל של ראיות-החוץ חייב שיהא רב למדי עד שיעלה בידיהן לגבור על הלשון הברורה" (עניין ארגון מגדלי ירקות, פסק דינו של השופט חשין בעמ' 52-53).

22. הנה כי כן, יש לבחון מתוך ההסכם, מה היה אומד דעת הצדדים בהגיעם אליו. זאת יש להסיק מלשון ההסכם, וכן מתכליתו ונסיבות עריכתו. כאשר המדובר בתקנון מוסכם, יש ליחס לצדדים פעולה בסבירות והגינות (ראה גם: ע"א 552/85, אגסי נ' ח.י.ל. חברה ישראלית לעבוד נתונים בע"מ, פ"ד מא(1) 241).

מן הכלל אל הפרט

23. לאור המקום הנכבד שניתן ללשון החוזה אבחן ראשית את לשון הסעיף השנוי במחלוקת. כותרתו של סעיף 3 לתקנון היא: "זכות בניה", משמע - סעיף זה בא להסדיר את מסגרת היחסים בין בעלי הדירות בבית המשותף בכל הנוגע לזכויות הבניה. את הוראת הסעיף יש לבחון על רקע היותו מסדיר סוגיה זו:

"כל בעל דירה יהיה רשאי בכפיפות לתנאי חוזה חכירה, להוסיף תוספת בניה לדירתו ובתנאי שקיבל תחילה את הסכמת מנהל מקרקעי ישראל והרשויות המוסמכות לתכנון ולבניה ובתנאי שהשטח הכולל של דירתו ושל תוספת הבניה שביצע ו/או שברצונו לבצע לא יעלו על חלקו באחוזי הבניה המרביים המותרים ו/או המאושרים לחלקה בשלמותה וחלקו זה יהיה כחלקה של דירתו ברכוש המשותף של הבית המשותף. הסכמת יתר בעלי הדירות בבית המשותף לבניית תוספת כלעיל, נתונה בזאת מראש.
עם תום הבניה יהא המבקש רשאי לפנות למפקח על רישום המקרקעין ולבקש תיקון צו רישום הבית המשותף, וזאת על מנת ליתן ביטוי משפטי לשינויים הפיזיים שחלו עקב הבניה הנוספת וההסכמה של בעלי הדירות האחרות נתונה מראש." (ההדגשות אינן במקור).

24. אקדים מספר מילים באשר למושג "זכויות בניה". זכויות הבניה אינן מוגדרות בחוק המקרקעין, והן אף אינן חלק מרשימת הזכויות המנויות בחוק המקרקעין. מושג זה צמח מתוך חיי המעשה (ראו: רע"א 2821/95 לוסטיג נ' מייזלס, פ"ד (1) 517, 527 (1996) (להלן: עניין לוסטיג); ע"א 10322/03 ישעיהו נ' שטרייכר, פ"ד נט(6) 449, 459-460 (2005) (להלן:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/296/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ענין שטרייכר; ע"א 7394/03 **נכסי ר.א.ר.ד. חברה לבניין בע"מ נ' מנהל מס שבח רחובות**, [פורסם בנבו] פסקה 14 (6.12.2006) (להלן: **עניין ראדד**); ע"א 467/14 **שרה דול שטינברג נ' חברת לילינבלום 13 בע"מ** (פורסם בנבו, 9.9.15) (להלן: **ענין לילינבלום**). ניתן לומר כי זכויות בנייה מבטאות את היקף וסוג הבנייה המותר במקרקעין לפי התוכניות הרלוונטיות החלות עליהם (ראו: ע"א 151/87 ש. ארצי, חברה להשקעות בע"מ נ' רחמני, פ"ד מג(3) 489, 503 (1989). זכויות הבנייה נגזרות מזכות הבעלות בנכס. לפיכך במקרה של בעלות משותפת במקרקעין, החלק היחסי של כל אחד מן הבעלים באחוזי הבנייה הוא בהתאם לחלק היחסי בבעלות (ראו: **עניין לוסטיג**, בעמ' 527). הדברים אמורים, בשינויים המחויבים, גם לגבי זכויות בנייה בבית משותף. כבר נפסק, כי זכויות הבנייה אינן נחשבות לחלק מן הרכוש המשותף עצמו אלא זהו נכס שנמצא בבעלות משותפת של בעלי הזכויות בדירות – בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף (ראו: ע"א 432/83 **מזרחי נ' חביב**, פ"ד מ(4) 673 (1986); **עניין שטרייכר**, בעמ' 460-461).

25. כעת נשוב לבחינת לשון סעיף 3 לתקנון המוסכם. לשון הסעיף ברורה והיא מאפשרת לבעל דירה להוסיף לדירתו תוספת בניה בלי שיצטרך לקבל הסכמת בעלי הדירות האחרים אך זאת בתנאים מסויימים: 1. קבלת הסכמת מינהל מקרקעי ישראל; 2. הסכמת רשויות התכנון; 3. השטח הכולל של דירתו לרבות התוספת לא יעלה על חלקו באחוזי הבניה המירביים המאושרים לחלקה שנגזר מחלקו ברכוש המשותף. בהתקיים תנאים מצטברים אלו הסכמת בעלי הדירות האחרים נתונה לו מראש. אין לקבל אם כך את הפרשנות אותה מציעים התובעים ולפיה לא ניתן כלל לבנות תוספת בניה כלשהי בלי לקבל את הסכמת בעלי הדירות על פי סעיף 71ב לחוק המקרקעין. פרשנות זו כלל אינה מתיישבת עם לשון הסעיף.

26. יצוין, כי הנתבעים ניסו לשפוך אור על אומד דעת הצדדים על ידי כך שהציגו את חווי הרכישה מול הקבלן של בני הזוג וינטראוב (צורפו כנספחים א1 וא2 לתצהיר קמחי) והפנו לסעיף ממנו עולה כי כל זכויות הבניה שיוותרו ולא ינוצלו בחלקה הם רכוש הקבלן וכן לסעיף הקובע כי זכויות הבניה יוצמדו לחלק מן הדירות והקונה מתחייב לתת הסכמתו לניצול זכויות בניה אלו. מקובלת עלי טענת התובעים לפיה סעיפים אלו אין בהם כדי ללמד דבר וחצי דבר שכן מה שנקבע בסופו של יום בתקנון המוסכם אינו דומה להם כלל שכן זכויות הבניה נותרו רכוש משותף ולא נותרו בבעלות הקבלן או הוצמדו לדירות מסויימות בלבד. מעבר לכך לא הוצגו ראיות נוספות הנוגעות לעריכת התקנון ולא הובא לעדות עורך התקנון משכך יש להסתפק בלשון הסעיף.

27. יצוין, כי סעיף דומה בתקנון מוסכם בבית משותף בירושלים נידון על ידי כב' המפקחת על רישום מקרקעין יעל ענתבי שרון בתיק 79/15 **טוביה ויסברוד נ' אסתר אברהם** (5.5.16), לא פורסם) ובו נדחתה עמדה דומה לזו המוצגת על ידי התובעים כאן לפיה למרות הסעיף יש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/296/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לדרוש הסכמות על פי סעיף 71ב לחוק המקרקעין. פסק דינה של כב' המפקחת ענתבי שרון אושר על ידי בית המשפט המחוזי (כב' הש' אלכסנדר רון בעש"א 45920-06-16 **אסתר אברהם נ' טוביה ויסברוד** (פורסם בנבו, 16.3.17).

28. יחד עם זאת ברור מלשון הסעיף כי הבניה אותה ניתן לנצל ללא הסכמת בעלי הדירות מוגבלת היא כך שהשטח הכולל של הדירה לרבות התוספת לא יעלה על חלקו באחוזי הבניה המירביים. באשר להיקף אותו ניתן לבנות ללא הסכמת יתר בעלי הדירות מציעים הצדדים פרשנויות שונות. לשיטת התובעים יש לחשב את סל זכויות הבניה בחלקה עליה בנוי הבית המשותף. הסל מורכב מזכויות הבניה על פי התכנית המקורית (מד/מב/2) וכן זכויות הבניה שהתווספו על פי התב"ע אותה יזמו הנתבעים (מד/מק/2/23). התובעים מבחינים לצורך חישובם זה בין זכויות בניה אותן ניתן לנצל לבניית שטח עיקרי לבין זכויות בניה אותן ניתן לנצל לבניית שטחי שירות. סל זכויות הבניה אותן ניתן לנצל לבניית שטח עיקרי עומד לפי התכנית המקורית (מד/מב/2) על 6,300 מ"ר. לפי התב"ע אותה יזמו הנתבעים נוספו 588 מ"ר עיקרי לחלקה לפיכך סל הזכויות עומד על 6,888 מ"ר. חלקה של כל דירה מדירות הנתבעים ברכוש המשותף עומד, כך על פי נסח הטאבו, על 7/540 כך שסך שטחים עיקריים שניתן לבנות כולל מה שכבר בנוי בלי לקבל את הסכמת יתר בעלי הדירות לא יעלה על $6,888 \times 7/540 = 89.28$. הנתבעים, כך על פי חוות הדעת האדריכלית שהוגשה מטעמם של האדריכלית איילת מארטינוטי, אינם מפרידים בין שטחים עיקריים לשטחי שרות ואת סל זכויות הבניה הם גוזרים רק מן התכנית המקורית שחלה על הבית המשותף (מד/מב/2) ומתעלמים מן התב"ע החדשה אותה יזמו (מד/מק/2/23). לפי הנתבעים סך המטרים שניתן לבנות מכוח התכנית המקורית עומד על 10,760 מ"ר (6300 מ"ר עיקרי ו-4,460 מ"ר שרות). את סך המטראז' הנ"ל הם מכפילים בחלקם של דירות הנתבעים ברכוש המשותף ומגיעים לתוצאה לפיה ניתן לבנות עד לגודל של 139.48 מ"ר כולל מה שבנוי כבר. הנתבעים אינם מבחינים בין שטחים עיקריים לשטחי שירות ולשיטתם ניתן לבנות 139.48 שטחים עיקריים.

29. בשאלה מהו ההיקף אותו ניתן לבנות על פי סעיף 3 לתקנון הצדק עם התובעים ואני מקבלת את עמדתם. סל זכויות הבניה נגזר מכל התכניות החלות על החלקה. כלומר יש להתייחס לשתי התוכניות ולא רק למקורית כפי שעשתה האדריכלית מטעם הנתבעים. בנוסף מקובלת עלי עמדת התובעים לפיה עת נגזר החלק של כל בעל דירה בסל זכויות הבניה יש להבחין בין שטחים עיקריים לשטחי שירות. משמעות הדברים היא כי להכפיל את חלקם של כל אחת מדירות הנתבעים ברכוש המשותף (7/540) בסך השטחים העיקריים אותם ניתן לבנות ובסך שטחי השרות. מכפלה זו מביאה למסקנה לפי סך השטחים העיקריים שיכולים הנתבעים לבנות לא יעלה על 89.28 כולל מה שכבר בנוי. באותה מידה יש להכפיל את אותו החלק בסך שטחי השרות ומתוצאה זו נקבל את סך שטחי השרות אותם יכולים הנתבעים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/296/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לבנות כולל מה שכבר בנוי. לא יתכן מצב בו החלק ברכוש המשותף יוכפל בסך השטחים המירביים הכוללים שטחי שירות ועיקרי והנתבעים יוכלו לנצל את זכויות הבניה הנזקפות כשטחי שירות לטובת שטחים עיקריים. אם פרשנות זו תתקבל היא תגרום לכך שבעלי הדירות הראשונים שיממשו את זכותם לבנות בלי הסכמת שכניהם "יחסלו" את סל השטחים העיקריים ויתירו לבאים אחריהם שטחי שירות בלבד, דבר שאיננו מתקבל על הדעת. לפיכך מקובלת עלי עמדת התובעים (החלופית) ואני קובעת כי הנתבעים יוכלו לבנות כך שסך השטחים העיקריים אותם יוכלו לנצל לא יעלה על 89.28 כולל דירתם שכבר בנויה. על פי אותו מפתח יש לחשב את שטחי השירות המקסימליים אותם יוכלו הנתבעים לנצל כולל מה שכבר בנוי. מתקנון התב"ע אותה יזמו הנתבעים עולה כי תב"ע זו הוסיפה רק 588 מ"ר עיקרי ולא שירות כך שאת שטחי השירות יש לחלץ מן התכנית המקורית החלה על החלקה. על פי תקנון תכנית זו סך שטחי השירות עומד על 4,460 מ"ר ולכן סך שטחי השירות שיוכלו לבנות הנתבעים כולל מה שכבר בנוי יעמוד על $4,460 \times 7/540 = 57.81$. כלומר סך שטחי השירות בדירת הנתבעים לרבות התוספת לא יעלה על 57.81 מ"ר. מן החומר המונח בפניי עולה כי התוספת המתבקשת לכל דירה מדירות הנתבעים עומדת על סך של 700 מ"ר (סעיף 11 לתצהיר ליזי מור ההנדסאית שהגישה את הבקשה להיתר מטעם הנתבעים) כשכמעט כל השטחים הם שטחים עיקריים (ראו נספח ב' לתצהיר קמחי – החלטת הועדה המקומית מיום 19.6.17 לפיה סך שטחי השירות הנוגעות ל-4 דירות (2 דירות הנתבעים ועוד שתי דירות נוספות) המבוקשים להיבנות עומד על סך של 13.13 מ"ר. עולה אפוא כי כמעט כל התוספת המבוקשת על ידי הנתבעים היא בניית שטחים עיקריים. מנספח א' לכתב ההגנה שהוא חישוב שטחים שנעשה על ידי האדריכלית נעמי גלברט שערכה והגישה את התב"ע מטעם הנתבעים עולה כי סך השטחים העיקריים הבנויים היום בדירות הנתבעים מגיע ל-73.77 מ"ר יחד עם זאת עולה מחישוביה של הגב' גלברט כי שטח ממ"ד של 7.5 מ"ר נכלל בשטחים העיקריים ואילו מתקנה 9(ד1) לתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), תשנ"ב-1992 עולה כי שטח מינמלי נדרש של ממ"ד ייכלל במניין שטחי השירות ולא במניין השטח עיקרי: "... **במרחב מוגן דירתי יראו כשטח שירות בדירת מגורים רק את השטח המזערי הנדרש לפי התקנות בענינן, (...).** השטח המזערי הנדרש נקבע בתקנה 197א לתקנות ההתגוננות האזרחית כדלקמן: שטח המרחב הדירתי לא יפחת מ-9 מ"ר (נטו, לא כולל קירות); נפח המרחב הדירתי לא יפחת מ-22.5 מ"ק; ואולם רשות מוסמכת רשאית לאשר מרחב מוגן דירתי בשטח או בנפח קטנים יותר, אם ראתה שהתנאים ההנדסיים במקום לא מאפשרים בניית מרחב מוגן דירתי בשטח ובנפח כאמור, ובלבד שלא תאשר מרחב מוגן דירתי בשטח הקטן מ-5 מ"ר (נטו, לא כולל קירות) ובנפח הקטן מ-12.5 מ"ק. עולה אפוא כי לשם חישוב השטחים העיקריים אותם ניצלו הנתבעים וכדי להגיע לשטח העיקרי אותו יוכלו לנצל יש להחסיר את שטח הממ"ד המזערי ככל שאכן קיים ממ"ד בדירה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/296/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

30. אשר על כן אני מקבלת את טענתם החלופית של הנתבעים וקובעת כי סך השטחים העיקריים אותם רשאים הנתבעים לבנות (כולל דירתם הבנויה זה עתה) לא יעלה על 89.28 מ"ר וסך שטחי השרות (לרבות הבנוי עד כה) לא יעלה על 57.81 מ"ר. ככל שירצו לבנות מעבר לכך יצטרכו לקבל את הסכמת בעלי הדירות הנדרשת על פי סעיף 71 ב לחוק המקרקעין. בין הצדדים נטועה מחלוקת אף בשאלה האם רוב זה ייגזר מהכניסה הספציפית בה מתגוררים הצדדים להליך דן או שמא יש לגזור את הרוב מכלל בעלי הדירות בבית המשותף אשר הינו בית מורכב ומונה 60 שירות. הנתבעים לא הציגו הסכמות הרוב הנדרש על פי סעיף 71 לחוק המקרקעין (3/4 מבעלי הדירות ש 2/3 מן הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם הן מן הכניסה הספציפית והן מן הבית המשותף כולו ולפיכך איני מוצאת מקום לדון בשאלה זו כעת שכן היא תיאורטית בלבד. יחד עם זאת אציין כי הפסיקה אינה תמימת דעים באשר לשאלה זו וקיימות בעניין זה פסיקות שונות (ראו למשל ע"א (מחוזי חיפה) 2821/01 וילסקר נ' לויט (פורסם בנבו 8.8.02) וכן עש"א (מחוזי חיפה) 36004-06-12 פלאוט נ' הוד (פורסם בנבו, 7.6.13) בהם נקבע כי הרוב הדרוש יבחן מקרב כלל בעלי הדירות בכל המבנים לעומת זאת בעש"א (מחוזי חיפה) 17756-02-12 שנורמן נ' כהן (פורסם בנבו 14.1.13) נקבע כי יש לבחון את הרוב הדרוש רק מקרב בעלי הדירות להן הוצמדה החצר כהצמדה משותפת. נוטה אני לסבור כי הרוב הנדרש צריך להיגזר מכלל בעלי הדירות בבית המשותף ולא מן הכניסה הספציפית – יחד עם זאת כיון שלא הוצגו לי הסכמות משני הסוגים איני נדרשת לקבוע מסמרות בענין.

31. מקובלת עלי טענת הנתבעים לפיה חוות הדעת השמאית שהוגשה מטעם התובעים אינה רלוונטית כלל לתיק. מדובר בחוות דעת המעריכה את שווי התוספת המתבקשת והרי עניינה של תביעה זו איננו כספי כלל ועיקר ולכן לא ברור מה טעם מצאו התובעים להגישה.

32. באשר לשטח המשותף שברצון התובעים להסב לשתי חניות לא מוצמדות הרי שלשם כך נדרשת הסכמת רוב מתוך כלל בעלי הדירות בבית המשותף והסכמה זו לא הוצגה לי. סעיף 4 לתקנון המוסכם קובע כי: "למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקרקע של הבית הינה רכוש משותף, המשותף לכל הדירות בבית". החניות אותם מבקשים הנתבעים לבנות הן על גבי הקרקע המשותפת ומשכך על ההסכמה להיגזר מכלל בעלי הדירות בבית. אמנם בעל דירה רשאי לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף אף בלא אישורה של האסיפה הכללית ובלבד שמדובר בשימוש רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן אשר אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ראו ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה פ"ד כח(1) 645) יחד עם זאת בניית שני מקומות חניה בחצר אינה מהווה שימוש סביר ולפיכך נדרשת הסכמת רוב בעלי הדירות בבית המשותף וזאת לא הוצגה לי (ראו לענין זה פסק דינה של כב' המפקחת דגנית קציר ברין בתיק 106/15 נחמיאס ואח' נ' איסק פארי ואח' (פורסם בנבו, 12.4.16) אשר אושר על ידי בית המשפט המחוזי בעש"א 44583-05-16 איסק פארי ואח' נ' נחמיאס ואח' (פורסם בנבו,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/296/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

8.11.16) ואף על ידי בית המשפט העליון ברע"א 9645/16 איסק פארי נ' נחמיאס (פורסם בנבו, 10.1.17) אשר אוזכר על ידי התובעים). אשר על כן אני מקבלת את טענת הנתבעים גם בנקודה זו ואוסרת על הנתבעים להסב את השטח המבוקש לחניות.

33. מקובלת עלי טענת הנתבעים באשר לטענת התובעים המסתמכת על סעיף 7 לתקנון ואכן יישום דקדקני של סעיף זה ירוקן מתוכן את סעיף 3 לתוכן ולא לכך התכוון המשורר. יפים לעניין זה דבריה של כב' המפקחת יעל ליבוביץ בפסק הדין אשר הובא על ידי הנתבעים בעניין 11/15 אילן אלפסרי ואח' נ' אבי יונגר (פורסם בנבו, 21.4.15):

"אם תתקבל פרשנות התובעים לפיה בכל מקרה בו בעל דירה מבצע שינויים בקירות החיצוניים תידרש לו הסכמת יתר כל בעלי הדירות ביית, יוצא כי הוראה זו מרוקנת מכל תוכן את הוראות סעיפים ... לתקנון, שהרי כל בניית תוספת לדירה, לא כל שכן כזו שמנצלת אחוזי בניה, כרוכה בביצוע שינויים בקירות החיצוניים וימצא כי בעוד שמתקין התקנון ביקש לאפשר ביצוע תוספות בנייה ללא צורך בהסכמות בעלי הדירות בבית, כל תוספת בנייה בהיותה משנה קירות חיצוניים תהיה כרוכה בהסכמה של בעלי הדירות "

ד. סוף דבר:

34. התביעה מתקבלת חלקית במובן זה שטענתם החלופית של התובעים מתקבלת.

35. ניתן בזה צו מניעה האוסר על הנתבעים להרחיב את דירותיהם מעבר ל-89.28 מ"ר שטחים עיקריים ו-57.81 מ"ר שטחי שירות וכן ניתן צו מניעה האוסר על הנתבעים להסב שטח מן הרכוש המשותף לטובת שתי חניות.

36. בנסיבות העניין אני מחייבת את הנתבעים בהוצאות משפט לטובת התובעים בסך של 6,000 ש"ח.

37. הסכום המפורט לעיל ישולם תוך 30 יום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, 21.5.2020, כ"ז אייר תש"פ, בהעדר הצדדים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/296/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ציפי קוינט-שילוני

מפקחת על רישום מקרקעין